



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 119/11
בקשה מס' 6/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

אביגיל חיים ת.ז. ת.ז. 057282071
מרחוב תרצה 4 דירה 16 ירושלים

המבקשת:
הנתבעת

- נ ג ד -

נציגות הבית המשותף רחוב תרצה 4 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד חנן גפני
מרחוב שחראי 24 ירושלים

המשיבה:
התובעת

ה ח ל ט ה

בפני בקשה סילוק התובענה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית למפקח לדון בתובענה. הטענה הועלתה על ידי המבקשת במסגרת הדיון בתובענה מיום 03.01.12.

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב תרצה 4 ירושלים הבנוי על חלקה 55 בגוש 30161 (להלן: "הבית"). הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

המבקשת טוענת כי סמכותו של המפקח מצטמצמת לסוגיות הקשורות ברכוש המשותף בלבד בעוד שהסעד ההצהרתי המבוקש עניינו ברכוש פרטי של המבקשת. כמו כן הוגש כבר כנגד המבקשת הליך בבית המשפט לעניינים מקומיים בגין הפרגולה שנבנתה ולפיכך קנתה הערכאה הנ"ל סמכות לדון בתובענה. כן טוענת המבקשת כי הגב' בן סימון איננה נציגות חוקית של הבית ולפיכך אין ישות משפטית הזכאית להגיש תובענה בהליך דנן וכי שער הברזל נבנה לפני למעלה מ- 4 שנים ולפיכך חלה התיישנות לגבי תביעה זו.

המשיבה טוענת כי בהתאם להוראות הדין נציגות הבית מוסמכת להגיש התובענה, כי הנציגות נבחרה כדין וממילא ישנה הודאת בעל דין בדבר היותה של הגב' בן סימון נציגות הבית, כי תקופת התיישנות מינימאלית של 7 שנים טרם חלפה, כי טרם התקיים כל דיון ענייני בבית המשפט לעניינים מקומיים ומכל מקום התובעת שם הינה עיריית ירושלים ולא התובעת דנן זאת בנוסף לכך שבית המשפט לעניינים מקומיים דן בהיבט הרישוי בלבד. המשיבה טוענת גם כי למפקח הסמכות ליתן צו הריסה בשטח פרטי בהתאם להוראות הדין ופסיקה.

המבקשת מסרה תגובה לתשובת המשיבה בהתאם להחלטתי מיום 18.01.12.

עוד בטרם אכנס לפירוט טענות המבקשת בתשובתה אציין, כבר עתה, כי התשובה לתגובה חרגה ממסגרת סיכומי תשובה המותרים על פי דין. סיכומי התשובה מותרים אך כתשובה לטענות המשיבה ואין המדובר באפשרות ל"מקצה שיפורים" לבקשה תוך הוספת טענות שלא נכללו במסגרת הבקשה המקורית או סיכום הטענות בעניינה, שהרי אין לכך סוף. אם תוסיף המבקשת בתגובה טענות שלא הועלו במסגרת בקשתה המקורית תהיה זכות תגובה למשיבה וכן הלאה. בדרך זו לעולם לא יסתיים סיכוב הגלגל וזאת בודאי שלא מתירות הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 119/11
בקשה מס' 6/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

בתגובתה לתשובה טוענת המבקשת כי שער הברזל הוצב בהסכמת המשיבה ולפיכך קמה טענת ההתיישנות, ההסכמה בדיון בפני המפקח היתה למינויה של הגב' בן סימון כנציגות באסיפה שתכונס אולם המשיבה הפרה את ההסכמה. המבקשת שבה וחוזרת על טענותיה כי המדובר בקניין פרטי ואין סמכות למפקח לדון בתובענה ומכל מקום הסמכות המקבילה היא לבית המשפט ולא למפקח.

המשיבה מסרה תגובה לתשובה לאור חריגת המבקשת מהמותר בסיכומי תשובה ולאור הכללתן של טענות נוספות, השמצות והכפשות לטענתה. אולם, מאחר וכאמור לעיל לא התייחסתי לטענות המבקשת אשר חרגו מהמותר בסיכומי תשובה (ומהמקובל ככלל בכתבי טענות), אינני נזקק להתייחס לתגובה זו.

דיון

העדר ידיבות

כבר בפתח הדברים יוזכר כי בהליך דנן כבר הוגשה בקשה לדחיית התובענה על הסף (תיק בקשה 119/11) במסגרתה נטען כי הגב' בן סימון איננה הנציגות החוקית של הבית ולפיכך יש מקום לסילוק התובענה על הסף. בקשה זו נדחתה בהחלטותי מיום 02.10.11 ומיום 08.11.11 ולפיכך אין בכוונתי לשוב ולדון בטענות ממוחזרות השבות ומועלות במסגרת הבקשה דנן.

לכך יש להוסיף, כבר עתה, כי בדיון מיום 13.12.11 חזרה בה המבקשת מטענתה כאילו הגב' בן סימון איננה הנציגות החוקית של הבית והחלטתה בהקשר זה כבר ניתנה בגמר הדיון (לבקשת המבקשת!). משכך, ממילא קיימת הודאה של המבקשת בהקשר זה ואין בבקשתה דנן כל הצדק להתיר לה לחזור בה מהודאתה זו. זאת ועוד. טענת המבקשת בתגובתה כאילו הוסכם בדיון בפני מיום 13.12.11 על מינויה של הגב' בן סימון באסיפה שתכונס, אין לה כל זכר בפרוטוקול הדיון הנ"ל וממילא אין הטענה האמורה משקפת את אשר התרחש באותו הדיון.

התיישנות

כאמור לעיל המבקשת טוענת בסיכומיה כי יש לסלק את התביעה בנוגע לשער הברזל על הסף מחמת התיישנות. על אף שהבקשה שהעלתה המבקשת בדיון בפני עסקה רק בשאלת הסמכות העניינית, חרגה היא במסגרת סיכומיה והעלתה את טענת ההתיישנות כאמור. די בכך להביא לדחיית הטענה. אף על פי כן, מצאתי לנכון לדון בטענה ולדחותה גם לגופה.

ראשית, טענת המבקשת היא כי שער הברזל הותקן לפני למעלה מ-4 שנים ולפיכך קמה טענת התיישנות. דא עקא, תקופת ההתיישנות המינימלית הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"), הינה 7 שנים, וממילא תקופה זו לא חלפה, גם לגישת המבקשת (ר' סעיף 15(1) לחוק ההתיישנות).

שנית, המדובר בהליך דנן בטענה בדבר הסגת גבול של המבקשת לשטח הרכוש המשותף. הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 119/11
בקשה מס' 6/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב הענינים הפוגע..." (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם).

בספרות המשפטית נאמר כי "הדין רואה עקרונית מעשה או מחדל כ'נמשכים' וכמולידים עילות תובענה מעת לעת, באותם מקרים בהם נתון הדבר בכוחו של העושה (או החדל) להפסיק מעשהו או מחדלו ובדרך זו שלא עוד לעשות עוולה או לגרום נזק ובלבד שאותה 'המשכיות' אינה נסמכת לאחור אל מעשה חד פעמי" (טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7). משכך, ממילא לא התיישנה עילת התביעה בהקשר זה.

שלישית, סעיף 3 לחוק ההתיישנות קובע כי "אין נזקקים לטענת התיישנות אם לא טען הנתבע טענה זו בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התובענה". במקרה דנן בודאי שחלפה ה"הזדמנות הראשונה" להעלאת טענת ההתיישנות, על פי כל פרשנות למונח זה.

המבקשת הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף וטענת ההתיישנות חייבת היתה להופיע כבר שם. אף אם נרחיב את מעגל ה"הזדמנות הראשונה" הרי שודאי שהיה על הנתבעת לכלול טענה זו במסגרת כתב ההגנה מטעמה. נוסף לכך הרי שבתיק זה התקיימו עוד שני דיונים מיום 13.12.11 ומיום 03.01.12. גם בדיונים אלו לא העלתה המבקשת טענתה זו, והיא "נזכרה" בה רק בסיכומים מטעמה בטענה בדבר העדר סמכות עניינית (שהוגשו ביום 10.01.12).

רביעית, ההבהרה בתשובת המשיבה כי טענת ההתיישנות מקורה בכך שהשער הוצב בהסכמת התובעת אך מחזקת את האמור לעיל כי אין המדובר בטענת התיישנות ובודאי שלא בטענה המצדיקה סילוק התובענה על הסף. ויודגש, מעבר לעובדה כי על המבקשת להוכיח במסגרת ראיותיה כי נתקבלה בידה הסכמה כאמור, הרי שעליה להוכיח גם כי המדובר בהסכמה בלתי הדירה. מכל מקום, זאת ניתן לעשות רק במסגרת מסכת הראיות ובודאי שלא בהליך מוקדם לסילוק על הסף.

היעדר סמכות עניינית

אין בידי לקבל את טענת המבקשת בכל הקשור להעדר סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה בנוגע לבניית הפרגולה והמבנה בחצר הבית.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 119/11
בקשה מס' 6/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

בהתאם להוראות הדין גדר הסמכות העניינית נקבע על פי העילה והסעדים המפורטים בכתב התביעה.

לטענת התובעת פעולות המבקשת בחצר הבית גרמו למפגע מכער אשר פגע ויפגע בערך של הנכסים בבית (סעיף 5 לכתב התביעה). כן נטען כי המבנה בחצר גורם לנזקים ומטרדים נוספים (סעיף 6 לכתב התביעה). התובעת מבקשת כי ינתן צו המורה על הריסת הפרגולה.

ראשית, עילת התביעה, כפי שנוסחה, עניינה בפגיעה ברכוש המשותף של הבית ובדירות אחרות - הטענה המרכזית הינה למפגעים חזותיים ונזקים אחרים לערך הנכסים בבית.

סעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע כי: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה" (ההדגשה שלי, א.ס.).

טענת התובעת היא כי המבקשת מפירה את הוראות התקנון החל על הבית. משכך, המדובר בתובענה שעילתה הפרת הוראות התקנון ובהתאם להוראות סעיף 72(א) לחוק המקרקעין לא רק שעילה זו מצויה במסגרת סמכותו העניינית של המפקח, אלא שהיא מצויה במסגרת סמכותו הבלעדית!

שנית, אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי המפקח אינו מוסמך לדון אלא אך בעניינים הקשורים לרכוש המשותף. די בהקשר זה להפנות, למשל, להוראות סעיף 2(ב) לתקנון המצוי ולסעיפים 72(א) ו-72(ב) לחוק המקרקעין, מהם ניתן ללמוד על קיומה של סמכות למפקח לדון גם בתובענות שבין בעלי דירות בבית, ללא כל קשר לרכוש המשותף או לנציגות הבית.

שלישית, אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי המפקח אינו מוסמך ליתן את הצו המבוקש.

סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדין בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 119/11
בקשה מס' 6/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") קובע סמכות כללית לתת כל סעד: "כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו".

בע"א 44/72 שס טוב נ' פרובר פד"י כו(1) 617 פוסק בית המשפט כי: "בחקיקה הישראלית משמש הדיבור 'בית-דין' לתרגום המלה האנגלית TRIBUNAL. על-פי פרק ו', סימן ד' לחוק המקרקעין, הוסמך המפקח להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות וההוראות שבסעיפים אשר בסימן הנ"ל מעידות על כך שהוא צויד בכל הכלים הדרושים לשם מילוי תפקיד שיפוטי. על-פי סעיף 74 לחוק הנ"ל. סמכותו כסמכות בית-משפט השלום, ועל-פי סעיף 75 (א), המפקח חייב לנהוג על-פי דיני הראיות הכלליים, זולת אם רשם את הטעמים המצדיקים סטיה מהם מסעיף 76 יוצא כי הוסמך המפקח ליתן צווי-ביניים. והחלטתו, אם סופית היא ואם צו-ביניים, מבוצעת כפסק-דין של בית-משפט השלום, ואף ניתן לאכוף אותה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית-המשפט... נמצא, המפקח הוסמך לפסוק בסכסוך ולשם כך ניתנו בידו כל הסמכויות של בית-המשפט" (ההדגשה שלי, א.ס.).

הלכות מאוחרות עיגנו את סמכויותיו של המפקח הדן בסכסוך שבפניו כסמכויות בית משפט שלום (ראה, בין היתר, רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון פ"ד נה(1) 199 ובר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 נ' דן ירדני פד"י לח (4) 487) ואף הכירו במפורש בסמכותו של המפקח ליתן צו הריסה (ע"א 768/80 יוסף לחם נ' אליהו פומרנץ פד"י לה (3) 527).

לבסוף הרי שגם לא ברור מכתבי הטענות האם הפרגולה והמבנה בחצר אכן נבנו ב"שטח פרטי" כנטען על ידי המבקשת. זאת יהיה על הצדדים להוכיח במסגרת מסכת הראיות.

אין גם כל ממש בטענת המבקשת כאילו "קנה" בית המשפט לעניינים מקומיים סמכות לדון בתובענה ומשזו מתנהלת בפניו נשללת סמכותו של המפקח (ולמעשה סמכותה של כל ערכאה אחרת) לדון בהליך אזרחי באותו העניין.

המדובר בשני הליכים שונים לחלוטין המבוססים על מערכת דינים שונה - בעוד שבהליך בבית המשפט לעניינים מקומיים מדובר בתובענה המוגשת על ידי רשות התכנון ובסיסה אישום פלילי בגין הפרת הוראות דיני התכנון והבניה, הרי שההליך שבפני הינו הליך אזרחי קנייני שבין נציגות הבית לבין בעל דירה. בכל אחת מהערכאות נבחנים דינים אחרים וההכרעות יתבססו, ממילא, על מסכות עובדתיות רלבנטיות שונות. ויודגש, יתכן והתוצאה בשני ההליכים תהיה זהה, הריסת התוספת. אולם, יתכן גם והתוצאה תהיה שונה - כך יתכן ויתברר כי אין היתר לתוספת הבניה דבר שיצדיק, לכאורה, הרשעה בהליך הפלילי המנוהל בבית המשפט לעניינים מקומיים. אולם, קיומו או אי קיומו של היתר אינו הכרח לצורך ההכרעה בהליך האזרחי המתנהל בפניו. יתכנו נסיבות בהן גם ללא קיומו של היתר תדחה התובענה, למשל באם לא יוכח כי העבודות שבוצעו מפרות את הוראות התכנון המצוי כאמור.

יוצא כי אין כל קשר בין ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים לבין ההליך המתנהל בפניו וקיומו של זה אינו שולל או משפיע על קיומו של ההליך האחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 119/11
בקשה מס' 6/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

לאור האמור לעיל אני דוחה את הטענה בדבר העדר סמכות עניינית לדון בתובענה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית. אני דוחה אף את הטענות לסילוק התובענה מחמת התיישנות והעדר יריבות.

אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי גם בכך שתשובת המבקשת לתגובת המשיבה חרגה מהמותר על פי דין כאמור לעיל והצדיקה התייחסות המשיבה כפי שהוגשה.

לאחר שניתנו כל ההחלטות בבקשות המקדמיות השונות בתיק זה ולאור העובדה כי לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות לסילוק התובענה, אין מנוס אלא לקבוע את התיק לשמיעת ראיות.

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מהיום עם העתק ישירות לצד השני.

הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע עם העתק ישירות לצד השני.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. התנגדות שלא תוגש במועד כאמור לא תתקבל.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו (לרבות המומחים) לישיבת ההוכחות, אלא אם ויתר הצד שכנגד בכתב על חקירתו של עד.

נקבע לשמיעת ראיות וסיכומים בעל פה (ככל שיותיר הזמן) ביום 22.05.12 שעה 09:00.

ניתנה בלישכתי ביום י"ג שבט תשע"ב, 06 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין